

1500115-36.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... ré, no entanto, foi condenada em regime aberto pela prática de tráfico privilegiado. Assim, não se mostra necessário que seja prontamente inserida no regime fechado, pois não houve prática de crime com grave ameaça ou violência anteriormente, tampouco agora. Possível, no seu caso, a fixação do regime SEMIABERTO, postulado pelo Ministério Público, conforme autoriza a súmula 269 do E.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500115-36.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-36.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2046100/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 16280434 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 271/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2046100 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGÉNES SAULO AUGUSTO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra Diógenes Saulo Augusto da Silva e Bruna Rodrigues Alves Bimbati pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, eis que entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2021, agindo em concurso e com unidade de desígnios, receberam, em proveito comum, o telefone celular da marca Apple, modelo

Iphone 7, IMEI nº 356391101757576, avaliado em R\$ 2.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16, auto de avaliação de fls. 20 e auto de entrega de fls. 21), o qual sabiam ser produto de crime.

A denúncia de págs. 98/100 foi recebida aos 20 de abril de 2021 - pgs. 101/102.

Respostas à acusação apresentadas nas pgs. 125/128 e 129/132 alegando, em síntese, atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a ação penal.

Ausentes as hipóteses que pudessem ensejar a absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 135/136).

Durante referida solenidade, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, decretando-se a revelia dos réus, conforme mídia arquivada no SAJ - pgs. 177/179.

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido.

O Ministério Público requer a procedência da ação penal indicando os elementos que comprovam a materialidade e autoria. Entende ser clara a autoria delitiva. A mãe da vítima compareceu no local e Bruna aproximou-se dela para a troca. É claro e nítido que ambos os réus sabiam que o aparelho não lhes pertencia. Especialmente Diógenes tinha plena e clara certeza que o aparelho não lhes pertencia e não esclareceram como adquiriram a posse. Caso pretendessem agir de forma lícita, correta, deveriam ter restituído o aparelho à vítima ou entregado na delegacia. Nas pgs. 43/44 e 88/89 verifica-se que ambos são reincidentes. A pena deve ser exasperada. Em razão da reincidência e revelia deve ser fixado o regime semiaberto.

A defesa, por sua vez, reitera as razões das respostas à acusação. Sustenta atipicidade da conduta e ausência de justa causa, pois não restou comprovada a veracidade dos elementos indicados na peça flagrancial. O aparelho estava numa praça e não exposto à venda, de modo que não está configurada a receptação. É preciso que o agente tenha certeza da origem criminosa da coisa, conforme jurisprudência que citou. Faz-se necessária a identificação do delito antecedente identificando com clareza a origem do bem. O produto foi encontrado numa praça e a jurisprudência é uníssona no sentido de que a coisa mantenha seu caráter delituoso. O bem foi encontrado por terceiro de boa-fé. A conduta é legal, pois agiram em conformidade com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro evidenciando a atipicidade e falta de justa causa. Os réus possuem bons antecedentes, residência fixa e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça não sendo o caso de prisão cautelar, excepcional no nosso direito. Eles não são pessoas de alta periculosidade. O ônus probandi recai sobre quem alega e nada foi evidenciado nestes autos. O celular foi encontrado no banco da praça, sendo uníssona a jurisprudência pátria sobre a necessidade de que a coisa mantenha seu caráter delituoso. O bem foi devolvido à vítima, sem nenhum prejuízo. Requer a absolvição.

DECIDO.

1 -) DA SÍNTESE PROBATÓRIA

1. 1 -) DAS PROVAS DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva veio estampada no auto de apreensão de pgs. 16; auto de avaliação de pgs. 20 e auto de entrega de pgs. 21.

Houve, portanto, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido

a orientação que dimana do princípio da materialização do fato.

1.2 -) DAS PROVAS DA AUTORIA

A autoria, por sua vez, pode ser constatada a partir dos seguintes depoimentos:

Livia Matos Daniel disse que estava na praça do Epidauro com seus amigos e resolveram ir embora e começou a procurar o celular e não achou. Foi para casa e não achou o celular. Procurou no carro e não achou. No Domingo, fez o registro de ocorrência. Na segunda-feira um moço mandou mensagem no celular do namorado da depoente e queria R\$ 1.000,00 pelo celular ou outro celular. Seu namorado discutiu com ele. Sua mãe falou com ele e marcou um encontro na rodoviária para trocar o celular. Os policiais pegaram ele. Não viu o rapaz. Não foi até a rodoviária. Sua mãe não quis que fosse. O aparelho que estava com o rapaz de fato lhe pertencia. Não sabe quem é Bruna. Acha que ela é que estava com o celular. O rapaz estava no banheiro da rodoviária. Sabe que foi uma mulher que entregou o celular para sua mãe e o moço saiu de dentro do banheiro. Foi um rapaz que combinou tudo com sua mãe e foi a esposa dele que foi até o local.

Larissa Madruga dos Santos Matos Daniel disse que não presenciou furto nenhum e não sabe se foi ele quem furtou. Na verdade, ele entrou em contato no celular do namorado da filha da depoente e tentou uma negociação, mas não deu certo. Marcou um encontro e combinaram de levar um celular para trocar com ele ou dinheiro. Avisou a polícia e foi orientada a marcar um local. Quem veio ao encontro da depoente foi uma moça e lhe perguntou se ela estava com o celular. Falou que estava com um celular e que ia dar em troca. Perguntou se ela tinha trazido o celular da sua filha e ela confirmou. A polícia entrevistou e o rapaz estava escondido no banheiro e foi abordado. Combinou por ligação, mas não sabia quem era. O celular não tinha foto. Ele chegou a falar R\$ 2.000,00 e baixou ficou por R\$ 300,00 ou outro celular. A moça chegou, sentou do lado da depoente e perguntou: "A sra é a moça do celular?". Não conhecia nenhum dos dois. Não sabe como eles conseguiram o contato do namorado da filha.

João Carlos Mancuso informa que a mãe da vítima procurou a delegacia dizendo que o celular da filha foi furtado e estavam recebendo mensagens em outro telefone e a pessoa dizia que estava com o telefone furtado e queria dinheiro para fazer a devolução. Eles marcaram a rodoviária para a devolução. Ficaram de campana e lá chegando visualizaram a hora que chegou uma moça e sentou ao lado da mãe da vítima. Nesse momento saiu um rapaz de dentro do banheiro da rodoviária e se aproximou da mãe da vítima. Fizeram a abordagem e identificaram o Diógenes e a namorada dele. O réu confirmou que estava com o celular e tinha achado e estava negociando a entrega. Ele tem antecedentes criminais, salvo engano por roubo. Foi feito o flagrante delito.

Os réus, inequivocamente cientes da audiência, deixaram de comparecer ou apresentar qualquer justificativa.

Na fase inquisitiva, tem-se o interrogatório de Diógenes nas pgs. 07, que assumiu ter mantido a posse do celular pertencente a terceira pessoa, no caso, a vítima Livia.

2 -) DO DIREITO APLICÁVEL

Não há que se falar em flagrante preparado quando os policiais apenas aguardaram a consumação do ilícito, sem qualquer provocação ou induzimento, tratando-se o caso de flagrante esperado, de inquestionável legalidade.

A tese defensiva de atipicidade não prospera, pois a *fattispecie* não exige que o bem estivesse exposto à venda.

A denúncia imputa aos réus a conduta de "receber", em proveito comum, o telefone celular da vítima.

Não há dúvidas de que os réus mantiveram a posse do aparelho pelo qual pretendiam auferir vantagem ilícita para fins de restituição à proprietária de direito.

A alegação de que o celular foi achado vem ao léu, pois não encontra-se amparada em qualquer elemento de prova. Nem mesmo a versão autodefensiva dos réus foi colhida sob o crivo do contraditório para legitimar tal alegação.

Ademais, a própria vítima disse que procurou o celular na praça onde estava com seus amigos e não o encontrou, o que está em confronto com a versão do réu de que "encontrou um aparelho de telefone celular aparentemente abandonado em uma arquibancada da praça da municipal." - pg. 07.

Vale lembrar, ainda, que a apropriação de coisa achada é também fato criminoso, conforme inciso II do § único do art. 169 do Código Penal.

Inviável reconhecer qualquer boa-fé na conduta dos réus que de forma conjunta tentaram extrair vantagem ilícita da vítima e sua genitora a fim de restituir o celular que mantinham ilicitamente sob suas posses.

O dolo é manifesto e mais do que justa causa para a ação penal, tem-se que há provas suficientes para a condenação.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, impõe-se a procedência da ação penal para concretização dos escopos de prevenção geral e especial colimados pelo sistema punitivo.

3 -) DO VEREDITO, DOSIMETRIA E DEMAIS DETERMINAÇÕES:

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de páginas 98/100, para CONDENAR DIÓGENES SAULO AUGUSTO DA SILVA e BRUNA RODRIGUES ALVES BIMBATI pela prática do crime capitulado no artigo 180, caput, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal a culpabilidade é normal à espécie.

Sua conduta social e personalidade não devem influenciar negativamente a reprimenda, pois tal valoração implica apologia ao direito penal de autor, fenômeno antigarantista que não conta com o entusiasmo deste magistrado.

O motivo do delito não foi devidamente apurado e não autoriza acréscimo.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza.

As consequências não podem ser consideradas graves.

Atentando às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena no mínimo legal de

1(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa para cada réu.

Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que a ré foi condenada definitivamente aos 06.07.2020 nos autos Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500293-27.2020.8.26.0540 - pg. 89, enquanto Diógenes foi condenado definitivamente aos 02.12.2019 no processo Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0024289-85.2016.8.26.0050 (0003366-76.2017.8.26.0026) - pg. 43.

Assim, impõe-se acréscimo de 1/6, passando a pena ao patamar de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Não há falar-se em qualquer confissão, pois a versão do réu Diógenes apresentada apenas em solo policial não foi utilizada para formação da convicção judicial que se escorou nas demais provas coligidas.

À míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a pena supra.

Diante da reincidência de ambos os réus, fixo o regime FECHADO para o réu Diógenes, pois anteriormente condenado por roubo já experimentou condenação no mesmo regime e não se emendou. A ré, no entanto, foi condenada em regime aberto pela prática de tráfico privilegiado. Assim, não se mostra necessário que seja prontamente inserida no regime fechado, pois não houve prática de crime com grave ameaça ou violência anteriormente, tampouco agora. Possível, no seu caso, a fixação do regime SEMIABERTO, postulado pelo Ministério Público, conforme autoriza a súmula 269 do E. STJ.

Inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência.

Os réus poderão apelar em liberdade, pois não foi decretada prisão cautelar neste processo.

CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança da verba, pois defiro-lhes os benefícios da AJG, uma vez representandos por advogado dativo - art. 98, § 3º do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva observando o regime fixado;

) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República.

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado

para as anotações necessárias.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA